

1500545-18.2021.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

1ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

1500545-18.2021.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500545-18.2021.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonata Henrique Cardoso da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra JONATA HENRIQUE CARDOSO DA SILVA, devidamente qualificado(a) nos autos, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Narra a inicial acusatória que, no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 21h, na Rua Ismael Colete, altura do numeral 400, nesta cidade e comarca de Itápolis, JONATA HENRIQUE CARDOSO DA SILVA, vulgo "Cebolinha", qualificado às fls. 11, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 06 (seis) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 20,19 gramas, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17 e laudo de exame químico definitivo(fl. 73/74/75).

O(a) réu(ré) foi devidamente notificado(a), apresentando resposta escrita à fl. 7. Denúncia recebida em 30 de setembro de 2021, conforme decisão de fl. 77/78.

Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram inquiridas 02 testemunhas arroladas pela acusação e ____ testemunhas arroladas pela defesa, sendo, em seguida, interrogado o acusado. Após, o(a) representante do Ministério Público e

o(a) defensor(a) apresentaram alegações finais orais.
Os autos me vieram conclusos para sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

Não foram arguidas preliminares na defesa prévia ou nas alegações finais defensivas.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, “Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)” (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprе ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, “o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

No caso do delito de tráfico de drogas, são indícios suficientes para a condenação do(a) agente, dentre outros: a) a confissão da prática do crime; b) a apreensão de substância entorpecente em poder do(a) autor(a) do fato e/ou de dinheiro em espécie (normalmente fracionado em notas miúdas, não possuindo o(a) denunciado(a) explicação convincente para a origem do numerário), bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido flagrado por policiais em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes; e) a circunstância de o(a) acusado(a) ser conhecido no meio policial como traficante de drogas, responder a inquérito, já ter sido ou estar sendo processado, e/ou possuir condenação pela prática do referido delito. Em tais casos, ainda que o(a) autor(a) do fato não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, esses indícios (prova indireta) permitem que o magistrado conclua, em processo indutivo, ser ele(ela) traficante de drogas.

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 13/16), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 17), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 18), pelos autos de exame de corpo de delito (fls. 23/24 e 25/26), pelo laudo pericial toxicológico (fls. 66/68) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria é incontroversa.

Conforme narrado na denúncia, no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 21h, na Rua Ismael Colete, altura do numeral 400, nesta cidade e comarca de Itápolis, JONATA HENRIQUE CARDOSO DA SILVA, vulgo "Cebolinha", trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 06 (seis) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 20,19 gramas, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina, receberam denúncia anônima de que o denunciado, já conhecido nos meios policiais pela venda de substâncias entorpecentes, estaria no local fazendo o comércio ilícito.

Chegando ao sítio indicado, os agentes de segurança visualizaram o acusado que, juntamente com sua companheira, passou a caminhar para deixar o local em virtude da presença dos policiais.

Foi realizada abordagem de ambos, sendo que, com o denunciado, foi encontrada uma porção de cocaína, na forma de pedra, em sua mão. Continuando a revista pessoal, os policiais ainda localizaram outras cinco porções de cocaína, em saquinhos, na parte superior de suas nádegas, no interior de sua roupa.

Já com a companheira do acusado, identificada como Jéssica Graziela Domingues, foi encontrada a quantia de R\$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) em notas trocadas e moedas, sendo admitido, por ambos, que a quantia pertencia ao denunciado.

Vejamos.

O acusado JONATA HENRIQUE CARDOSO DA SILVA, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que "havia chegado do serviço por volta das 19 horas e disse que precisava ir ao mercado. Que juntamente com a sua mulher, Jéssica, pegaram o dinheiro, inclusive as moedas e se dirigiram ao mercado, sentido a Vila em que foram abordados. Que passou e pegou a droga, que pagou R\$ 10,00 (dez reais). Que pagou trinta reais por três porções de droga, cocaína. Que havia acabado de retirar a droga na boca de fumo e foi abordado. Que informou aos policiais que havia três porções de drogas na parte lateral da cueca e que Jessica afirmou que não portava. Que os policiais acharam apenas três porções em seu poder. Que usou droga (cocaína) por volta das 19 horas. Que a abordagem foi depois das 20 horas. Que estava na penitenciária de Avaíandava, que havia sido condenado por tráfico de drogas" (sic) (fl. 07).

Na audiência de instrução e julgamento, o(a) denunciado(a) JONATA HENRIQUE CARDOSO DA SILVA sustentou que na data dos fatos, após sair do trabalho foi até um ponto de venda de drogas e adquiriu alguns pinos de cocaína para usar. Em seguida, encontrou-se com sua esposa na esquina do cemitério, momento em que foram abordados pelos policiais. O dinheiro que estava com sua esposa era proveniente do trabalho do interrogado. Disse aos policiais que as drogas que estavam em seu poder eram para o seu uso. Negou-se a informar aos policiais o nome da pessoa que lhe vendeu os entorpecentes para evitar alguma retaliação. É usuário de drogas desde a adolescência e já respondeu por atos infracionais quando era menor de idade.

As testemunhas WILSON ROBERTO FURLAN e JENIFER FERRARESI BATISTA, policiais militares, em solo policial, disseram que "Em patrulhamento por volta das 21 horas, receberam uma denúncia via 190, informando que Jonata (vulgo cebolinha) estava com sua mulher traficando drogas pela rua Esmael Coletti, n. 400, que é de um bar. Se deslocaram para lá e avistaram o casal, que assim que o casal avistou a viatura, se assustaram e tentaram se evadir. Foi realizada a abordagem em ambos, com Cebolinha foi encontrado um involucro plástico contendo cocaína em pedra que estava na mão dele, continuando a busca pessoal foi encontrado na parte superior das nádegas cinco porções de cocaína embalados em saquinhos zip loque. Em busca pessoal que a policial feminina fez na mulher que acompanhava Cebolinha foi encontrada a quantia de R\$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) em notas trocadas e em moedas. Indagado a respeito das drogas afirmou que vendia cada porção a vinte reais a grama da cocaína que estava a granel e que o dinheiro que estava com a sua mulher seria dele. Que Jessica negou vender drogas e que apenas Cebolinha venderia droga. Que

com receio de fuga foi necessário o uso de algemas. Foi dada a voz de prisão a ambos em vista da traficância das drogas. Que Cebolinha é reincidente e que saiu há poucos meses da penitenciária pelo mesmo crime." (sic) (fls. 04/05).

Ao serem inquiridas na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas WILSON ROBERTO FURLAN e JENIFER FERRARESI BATISTA sustentaram que, na data dos fatos, receberam denúncia anônima, via 190, informando que o réu, vulgo "CEBOLINHA", e a esposa dele estariam vendendo drogas na Rua Ismael Coleti, na altura do numeral 400. Deslocaram-se até o local e avistaram o casal, que ao visualizar a viatura, tentou empreender fuga, sem êxito. Em busca pessoal, localizaram nas mãos do réu um invólucro contendo aproximadamente 21g de cocaína em pedra. Entre as nádegas e a cueca do acusado encontraram 5 porções de drogas. Também apreenderam com a companheira do réu a quantia aproximada de R\$ 394,00, dividida em notas pequenas e trocadas. O réu confessou que vendia a grama da cocaína a granel por R\$ 20,00 e que o dinheiro que estava com sua companheira lhe pertencia. O denunciado já era conhecido nos meios policiais quando menor de idade. Após completar a maioridade, o acusado já havia sido preso pela prática do tráfico de drogas. Não viram o casal entregando drogas ou pegando dinheiro de terceiros.

A testemunha JÉSSICA GRAZIELA DOMINGUES, ao ser ouvida na fase policial, relatou que "que chegou do trabalho por volta das 16hrs30min e saiu por volta das 19 horas, que teria saído de casa e foi para o mercado sozinha, fez a compra e pediu para que fosse entregue em sua residência. Que após isso, ligou para a tia de Jonata para saber se ele estaria na casa dela, pois ele reside com ela. Que ela disse que Jonata não estaria em casa. Que sabe que Jonata corta cabelo de alguns amigos por 10 ou 15 reais. Que encontrou com Jonata na Avenida e conversou com ele para irem embora. Que ficou cerca de 5 minutos com Jonata e já foi abordada pelos policiais. Que logo que chegou recebeu dinheiro de Jonata, que acredita que se trata ou dos cortes de cabelo ou do trabalho de servente de pedreiro. Que abordaram os dois separadamente. Que abordaram Jonata e escutou falar que foi encontradas três pedras de crack com Jonata e cocaína, que sabe que ele usa drogas e com a interrogada foi encontrado apenas o dinheiro. Que não sabe dizer se no local é ponto de drogas" (sic) (fl. 06).

Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais.

Além disso, é fato notório e de conhecimento geral que, nos crimes (e atos infracionais) de tráfico de drogas, impera a lei do silêncio, haja vista que a(s) testemunha(s) do fato, sentindo-se amedrontada(s) e temendo por sua integridade física e/ou de seus amigos e familiares, optam por se calar, por fornecer pouco(s) detalhe(s) a respeito da empreitada criminosa ou, simplesmente, por mentir à autoridade policial e/ou ao(à) magistrado(a). Em tal contexto, a(s) denúncia(s) anônima(s) e o(s) depoimento(s) de policiais civis e militares possuem grande valor probatório.

5. A defesa pleiteia a absolvição, ao argumento de que denúncias anônimas e/ou a simples intuição do policial não poderiam ter embasado a revista pessoal realizada no acusado, motivo pelo qual as provas colhidas seriam ilícitas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Não há como acolher tal pleito.

Inicialmente, cabe destacar que a ação dos policiais foi motivada pelo recebimento de denúncia anônima apontando que o denunciado e sua companheira estariam no local dos fatos praticando o tráfico ilícito de entorpecentes, cabendo destacar que o réu já era conhecido nos meios policiais como traficante de drogas.

Ressalte-se que denúncias anônimas são admitidas em nosso ordenamento jurídico, mormente se os fatos nela noticiados restarem posteriormente confirmados, como ocorreu no caso dos autos, haja vista que, ao diligenciarem no local indicado na denúncia, os policiais encontraram o réu e sua companheira na posse de drogas e de dinheiro cuja licitude não foi satisfatoriamente comprovada pelo imputado. Verifica-se, portanto, que havia fundadas razões (justa causa), devidamente

justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, autorizadores da busca pessoal no acusado, que trazia consigo drogas para posterior venda a terceiros, fato este confessado pelo acusado para os policiais que realizaram a diligência. Cumpre ainda destacar que o tráfico de drogas, nas modalidades guardar, ter em depósito, expor à venda, transportar e trazer consigo, é crime permanente que, como tal, se protraí no tempo. Por essa razão, é prescindível a existência de mandado de busca e apreensão, mormente quando a atuação policial está amparada em fundadas razões (justa causa) que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito. Em suma, quando o contexto fático anterior à busca pessoal permitir a conclusão acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas, é perfeitamente admissível a realização da prisão em flagrante, que poderá ser efetivada enquanto não cessar a permanência, independentemente de prévia autorização judicial. Nesse sentido, são os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016; AgRg no HC 651.377/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021; RHC 141.544/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021; HC 414.196/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017; HC 407.689/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017.

6. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do(a) acusado(a).

7. A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Nos termos do § 2º, do artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Tóxicos não exige que o agente seja flagrado praticando atos de mercancia para que sua conduta seja enquadrada no tipo penal do artigo 33, caput. Isso porque o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas").

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, "para alicerçar a pretendida condenação por tráfico não é necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública" (TJSP; Apelação Criminal 1500705-48.2018.8.26.0274; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019 - grifo meu).

Ademais, a condição de usuário ou dependente de drogas não é incompatível com a figura do traficante, tampouco afasta per si a imputabilidade do agente. Nesse sentido: TJMS, HC 01733320620158110000, Relator: Desembargador Gilberto Giralde, DJ 04/02/2016; TJDF, APR 0015443-41.2008.807.0001, Relator: Desembargador Souza e

Ávila, DJ 03/02/2010.

In casu, a quantidade de entorpecentes apreendida (20,19 gramas de cocaína) e sua forma de acondicionamento (em diversas porções, que facilitam o transporte e comercialização) revelam a intenção do(a) denunciado(a) de praticar a traficância ilícita.

Com efeito, conforme se extrai de julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo: a) um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5g a 1,0g do entorpecente; b) uma "fileira" de cocaína é confeccionada com 0,1g a 0,125g da droga, aproximadamente; c) uma pedra de crack tem, em média, 0,2g a 0,25g.

Confira-se: Apelação Criminal 1500949-81.2019.8.26.0228; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019; Apelação Criminal 0000617-39.2016.8.26.0247; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018; Apelação Criminal 0000244-11.2015.8.26.0613; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mococa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/10/2016; Data de Registro: 21/10/2016.

Com base nesses dados, conclui-se que a quantidade de droga apreendida (20,19 gramas de cocaína) seria suficiente para produzir diversas porções

individualizadas, ou seja, era destinada a entrega a consumo de terceiros.

Cabe ainda ressaltar que, embora o réu não tenha sido flagrado comercializando drogas, há nos autos elementos indicativos de que ele estava praticando o tráfico de drogas, entre os quais: a) a existência de denúncia anônima relatando que um casal estaria traficando drogas no local em que o denunciado e sua companheira estavam; b) o fato de o acusado ter sido flagrado por policiais em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes; c) a apreensão, em poder do acusado e de sua companheira, de dinheiro em espécie, fracionado em notas miúdas, não tendo o denunciado oferecido explicação convincente para a origem do numerário; d) o acusado é conhecido no meio policial como traficante de drogas, já tendo sido processado e condenado pela prática do referido delito.

7. É inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

In casu, verifico que o acusado é reincidente (processo n.º 0000298-80.2017.8.26.0556) e possui maus antecedentes (processo n.º 0002147-60.2017.8.26.0274).

Ademais, o responde a outro processo criminal, com denúncia oferecida, pela prática de delito de tráfico de drogas praticado antes daquele que é objeto da presente ação penal: processo n.º 1500017-47.2022.8.26.0274. Conforme já decidiu a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06" (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017 - grifo meu).

Finalmente, de acordo com os policiais militares, o acusado já é conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico de entorpecentes, tendo sido abordado por milicianos em ponto de venda de entorpecentes.

II.3 - Da dosimetria das penas

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada

circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

O agente possui Maus antecedentes, diante da existência de sentença(s) condenatória(s) transitada(s) em julgado relacionada(s) a fato(s) anterior(es) àquele que é objeto da presente ação penal e que não configura(m) reincidência: processo(s) n.º 0002147-60.2017.8.26.0274.

Considerando-se que o acusado ostenta 1 (uma) condenação definitiva que não configura reincidência, aumento a reprimenda em 1/6 e estabeleço a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no RESp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; RESp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Deixo de reconhecer a atenuante do artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, por se tratar de confissão qualificada. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: HC 119671, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013. Esse é também o entendimento do TJSP: Apelação Criminal 9000001-11.2014.8.26.0301; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jarinu - Vara Única; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019.

Reconheço a agravante da reincidência (processo n.º 0000298-80.2017.8.26.0556), razão pela qual aumento a pena-base em 1/6, e estabeleço a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de

diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. "Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p. 398 – grifo meu).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento no artigo 33, § 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal. Embora a quantidade de pena aplicada autorize, em tese, a fixação do regime semiaberto, os maus antecedentes e a reincidência indica(m) que o estabelecimento de regime carcerário mais gravoso é medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito que está sendo imputado ao agente.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

6. Substituição por penas restritivas de direitos.

Considerando-se a quantidade de pena aplicada, bem como a reincidência e os maus antecedentes, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, no caso concreto, a aplicação de penas alternativas revelar-se-ia inadequada para fins de reprovação e prevenção (geral e especial) do delito praticado pelo acusado.

7. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o acusado já foi contemplado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ademais, prevalece no STF e no STJ o entendimento de que o sursis é inaplicável aos crimes hediondos ou equiparados, pois a dimensão do benefício não se coaduna com a natureza do delito, em relação ao qual a própria CF, em seu artigo 5º, XLIII, determinou tratamento mais severo (STF, HC 101.919/MG; STJ, HC 197.268/SP).

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o(a) acusado(a) JONATA HENRIQUE CARDOSO DA SILVA como incurso(a) nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Nos termos do artigo 316, § único, e 387, § 1º, do CPP, mantenho a prisão preventiva do(a) acusado(a) e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, não ocorreu nenhuma modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, que continua necessária para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: "HABEAS CORPUS - Apelação em liberdade - Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal - [...] Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva - Ausência de fato novo - Inexistência de violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência - Precedentes do STF, STJ e TJSP - Ordem denegada [...]". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2262474-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020 - grifo meu).

3. Outras disposições

Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final. Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir prejuízo material constatado.

Transitada em julgado a sentença:

Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados.

Notifique-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88;

Porque não interessa a preservação das drogas apreendidas, oficie-se, determinando a incineração delas, mediante termo circunstanciado.

Demonstrado que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de drogas, decreto seu perdimento em favor da União Federal, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/2006.

Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itapolis, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA